

第43問

甲・乙・丙は、幹線道路に面した高層マンションを中心に住居侵入窃盗を繰り返していた者たちである。その手口はつぎのようなものであった。すなわち、徒歩の甲が、携帯電話を利用して、自動車で移動している乙・丙に対し、遠方から見て電気が灯っておらず留守のように見えるマンション内の住居を指示し、乙・丙が住居に侵入して窃盗をしている間は、当該マンションの近くで見張りをする、というものである。また、三者の間には、現金・金券・高級腕時計以外は絶対に盗まない、人に怪我をさせない、という合意があった。

ある日、乙・丙が甲の指示に基づいて、あるマンション内の住居に侵入したところ、留守だと思われた住居人Xは昼寝をしていただけで、逃げだそうとした乙と物音に驚いて目覚めたXとが揉み合い状態となり、乙を助けようとした丙がXの頭部をテーブル上にあった大理石製大型灰皿で殴ったため、Xは脳震盪を起こして失神した。その時点で、乙・丙は、空手のままで退出するか、犯行を続行するか、ということについて話し合った結果、こうなれば続行するしかないし、Xに怪我をさせたことは甲には黙っておけば良い、ということになり、Xの目や口をガムテープ等で塞いだ上で、宅内をあらさがしし、現金・金券・腕時計の他、指輪等の貴金属をも盗んだ上、逃走した。Xは、乙・丙の貼ったガムテープ等が鼻孔をも塞いだため、しばらくして窒息死するに至った。

以上の事案における、甲・乙・丙の罪責を論ぜよ。

(慶應義塾大学法科大学院 平成19年度 改題)

第1 乙・丙の罪責

1 まず、X宅に侵入した時点で住居侵入罪（130前段）が成立するのは問題がない。

2 次に、乙・丙は、意を通じて、Xを大理石製大型灰皿で殴り失神させ、ガムテープで目や口を塞いだ上で、現金・金券・腕時計のほか、指輪等の貴金属（以下「現金等」という。）をも盗み、結果としてXを死亡させているから、強盗致死罪の共同正犯（240後段、236 I、60）が成立することが考えられる。

(1) まず、Xを前記灰皿で殴打して失神させた上、ガムテープで目や口を塞いだ行為が強盗罪の客観的構成要件に該当することは問題ない。

(2) もっとも、Xを前記灰皿で殴打した時点では、反抗抑圧に足る暴行脅迫を加えることによって財物を奪取する意図はないから、この時点では強盗罪の故意は認められない。

一方、ガムテープでXの目や口を塞いだ段階では財物を奪取する意思が認められ、仮にガムテープでXの目や口を塞ぐ行為が「強取」に当たれば、強盗罪の故意を肯定することができる。これらのことから、いわゆる事後的奪取意思の論点が出てくる（**論点** 事後的奪取意思

 司H28,R2,18H2-2,H6-2）。

この点については、新たな暴行・脅迫があり、これを強盗罪の実行行為としての暴行・脅迫と評価することができる場合には、強盗罪が成立するという立場が一般的である（大阪高判平元.3.3、東京高判平20.3.19【百選Ⅱ42】）。そして、反抗抑圧後の新たな暴行・脅迫を「強取」行為とみるためには、それ自体反抗抑圧に足るものである必要はなく、自らの作出した反抗抑圧状態を継続させるものであれば足りると解されている（東京高判平20.3.19【百選Ⅱ42】）。

本問では、ガムテープで目や口を塞ぐ行為はそれ自体反抗抑圧に足る暴行ではないものの、Xの失神という反抗・抑圧状態を継続させるものであり、「強取」行為に当たる。したがって、その旨の認識のある乙・丙には強盗罪の故意が肯定でき、強盗罪の共同正犯が成立する。

(3) また、ガムテープで鼻腔と口を塞がれたことによって、Xは窒息死していることから、強盗致死罪の共同正犯の罪責を負う（240後段）。なお、乙・丙にその旨の認識はないから、強盗殺人罪は成立しない。

第2 甲の罪責

1 まず、住居侵入罪について乙・丙と共に共同正犯となるのは問題がない。甲は乙・丙と住居侵入窃盗についての事前共謀があり、共謀共同正犯となるからである（この点、甲が共同正犯になるのは明らかだから、共謀共同正犯についての論証はごく短く論じるべきである。）。

2 次に、乙・丙の強盗行為についてはどうか。この点、本問では甲に二つの錯誤が生じている。①一つは、現金・金券・高級腕時計以外は絶対盗まないという事前の合意があるにもかかわらず、乙・丙が指輪等の貴金属をも盗んでいる点、②もう一つは人に怪我をさせないという合意があるにもかかわらず、乙・丙はXに暴行を加え、結果Xを死亡させ

 205 頁  88 頁

ている点である（**論点** 共犯と錯誤～共同正犯（共同正犯の本質論）**論** 司
H20,H29,R3,旧H5-1,H11-1,H18-1,H20-1、**論点** 具体的事実の錯誤 **論** 司H30,予H24,旧H5-
2,H14-1）。

総合 154 頁 **論証** 63 頁
総合 37 頁 **論証** 7 頁

- (1) ①については、いわゆる具体的事実の錯誤の問題として処理することが可能であるから、この点に故意を認めることができる（法定的符合説）。
- (2) ②については、いわゆる抽象的事実の錯誤の問題として考えれば、甲に帰責できるのは窃盗罪の限度ということになる（同説）。
- (3) 以上からすれば、甲は現金等について窃盗罪の罪責を負い、乙・丙とは共同正犯の係に立つ（部分的犯罪共同説）。
- 3 もっとも、甲らの合意は現金・金券・腕時計以外は絶対盗まないというものであり、単純に「現金を盗もうと思っていたが、偶然指輪も見つけたからこれ幸いと盗んだ」というケースとは異なる。これに加えて、本問では乙・丙間に強盗の現場共謀が成立し、強盗行為が行われ、Xが死亡しているのである。

そうすると、甲からすればあまりにも意外な結果が生じているのであり、現金等にかかる窃盗罪の限度でも甲に帰責できるのかという疑問がある（**論点** 共謀の射程 **論** 司H20,H23,H29,R3,予H25,H30,旧H21-1）。つまり、乙・丙らの行為のうち、指輪の奪取及び強盗行為は事前共謀とは全く別個の新たな共謀に基づくものであり、甲はこれに対して何ら因果性を及ぼしていない以上、甲にはせいぜい住居侵入罪の限度でしか帰責できない（傷害結果についても帰責を認めるのであれば、甲には暴行の故意すら認められないだろうから、過失致傷罪（209）に問擬されるだろう。）という結論もあり得る。答案例はこの筋で論じている。

総合 135 頁 **論証** 53 頁

第1 乙及び丙の罪責

- 1 住居侵入罪（130前段）及び傷害罪（204）の共同正犯成立

↓

- 2 強盗致死罪（240後段）の共同正犯の成否

↓

強盗罪の客観的構成要件に該当する

↓

Xを前記灰皿で殴打した時点では、故意がない（38 I）

↓

事後的奪取意思

↓

新たな暴行・脅迫が必要

↓

あてはめ

↓

強盗罪の共同正犯成立

↓

強盗致死罪の共同正犯成立

↓

傷害罪はこれに吸収される

第2 甲の罪責

- 1 住居侵入罪の共同正犯成立

↓

- 2 強盗行為に関する共同正犯の成否

↓

共謀の射程

↓

因果性の有無で判断する

↓

あてはめ

↓

- 3 甲は住居侵入罪についてのみその罪責を負い、乙及び丙と共同正犯の関係に立つ

第3 罪数

乙及び丙は住居侵入罪及び強盗致死罪の罪責を負い、牽連犯（54 I 後段）となる

乙及び丙は共同正犯の関係に立つ

甲は住居侵入罪の罪責を負い、乙及び丙と共同正犯となる

第1 乙及び丙の罪責

1 乙及び丙が意を通じて窃盗目的でマンション内の住居に侵入した点については、「正当な理由がないのに、人の住居……に侵入」したものと

して、住居侵入罪の共同正犯が成立する（130条前段、60条）。

また、乙を助けるために丙がXを大理石製大型灰皿で殴り失神させた点については、乙及び丙が黙示的な意思連絡によって現場共謀を成立させ、人の生理的機能を害したものとして、傷害罪の共同正犯（204条、60条）が成立する。

2 続いて、乙及び丙は、現場で意を通じた上、Xの目や口をガムテープ等で塞ぎ、現金・金券・腕時計のほか、指輪等の貴金属（以下「現金等」という。）を盗み、結果としてXを死亡させているから、強盗致死罪の共同正犯（240条後段、236条1項、60条）の成立が考えられる。

(1) まず、Xを前記灰皿で殴打して失神させた上、ガムテープ等で目や口を塞いだことは、反抗抑圧に足る「暴行」である。そして、Xの反抗抑圧状態を利用して、現金等を盗んでいるから、「暴行……を用いて他人の財物を強取した」ものとして、強盗罪の客観的構成要件に該当する。

(2) もっとも、Xを前記灰皿で殴打した時点では、反抗抑圧に足る暴行脅迫を加えることによって財物を奪取する意図はないから、この時点では強盗罪の故意（38条1項）は認められない。

しかし、その後、財物奪取を目的とする新たな暴行・脅迫が加えら

1

れた場合は、それを「強取」行為とみることができる。そして、新たな暴行・脅迫はそれ自体反抗抑圧に足るものである必要はなく、反抗抑圧状態を継続させるものであれば足りる。

本問では、ガムテープ等で目や口を塞ぐ行為はそれ自体反抗抑圧に足る暴行ではないが、Xの失神という反抗抑圧状態を継続させるものであり「強取」行為に当たる。

したがって、その旨の認識のある乙及び丙には強盗罪の故意が肯定でき、強盗罪の共同正犯が成立する。

(3) また、ガムテープ等で鼻孔を塞がれたことによって、Xは窒息死していることから、乙及び丙は強盗致死罪の共同正犯の罪責を負う（240条後段）。前記傷害罪は本罪に吸収される。

なお、強盗致死罪の基本犯たる強取行為は、それ自体、死の結果が発生する危険性を内包するから、これを共同すれば結果まで帰責されると解すべきである。

第2 甲の罪責

1 まず、甲、乙及び丙による事前共謀に基づいて、乙及び丙がマンション内の住居に立ち入っていることから、住居侵入罪につき、乙及び丙と共に共同正犯となる。

この点について、実行行為を行っていない者であっても、60条の根拠である相互利用補充関係による共同犯行の一体性が認められる以上、「共同して犯罪を実行した」ものとして、共同正犯とみることには問題はない。

2

2(1) 次に、乙及び丙が現金等を強取し、Xを死亡させた点についてはどうか。甲が乙及び丙となした事前共謀の内容と乙及び丙の実行行為の内容が異なる以上、乙及び丙の実行行為に事前共謀の射程が及んでいないことが考えられる。

(2) 共謀の射程が及ばない場合とは、共謀と結果との間の因果性が欠ける場合をいう。そして、因果性が欠けるか否かは、共謀時の犯罪目的と実行分担者の犯罪目的とが異なるか、共謀の内容に実行分担者の行動を制約する要素があるか等をもって判断すべきである。

(3) 本問では、事前共謀の内容は現金・金券・腕時計以外は絶対盗まないというものであるのに対し、乙及び丙はその他指輪等の貴金属をも盗んでいる。また、人に怪我をさせないという合意があるにもかかわらず、乙及び丙はXに暴行を加え、結果Xを死亡させている。

これらの事実からすると、共謀時の犯罪目的と実行分担者の犯罪目的とが異なっている上、共謀の内容に実行分担者の行動を制約する要素もあるといえる。

さらに、乙及び丙の前記強盗の共謀は、Xと揉み合いになり、Xを殴打してしまったことを契機とするものであって、甲が及ぼした物理的・心理的影響は極めて軽微なものにとどまっている。このことは、乙及び丙が強盗の現場共謀を成立させた時点で、「甲には、黙っておけばよい。」と合意していることからもうかがわれる。

以上の事実を鑑みれば、乙及び丙が行った強盗行為については、前記事前共謀が因果性を及ぼしていることはなく、共謀の射程が及ばな

3

いとみるべきである。

3 したがって、甲は住居侵入罪についてのみその罪責を負い、乙及び丙と共同正犯の関係に立つ。

第3 罪数

乙及び丙は住居侵入罪及び強盗致死罪の罪責を負い、両罪は目的手段の関係にあるから、牽連犯（54条1項後段）となる。また、乙及び丙は共同正犯の関係に立つ。

甲は住居侵入罪の罪責を負い、乙及び丙と共同正犯となる。

以上

4